

0019403-14.2015.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes Previstos na Legislação Extravagante

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0019403-14.2015.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0019403-14.2015.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Previstos na Legislação Extravagante

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Ofício - 474/2015 - Central de Polícia Judiciária de Bauru, 2103/2015 - Tribunal de Justiça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UBIRATAN RICARDO GONÇALVES PORTUGAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

UBIRATAN RICARDO GONÇALVES PORTUGAL foi dado como incurso nas penas do art. 349-A do Código Penal, porque, no dia 10 de maio de 2013, por volta das 19h10, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru, na Rodovia Marechal Rondon, km 350, nesta cidade, ingressou em estabelecimento prisional com um aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 12 de janeiro de 2017 (fls. 136/137).

Citado (fls. 350), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 355/356.

Em audiência, foi ouvida uma testemunha e foi decretada a revelia do réu (fls. 429

- audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 433/434).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 438/441, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- não há laudo pericial do celular; 3)- a testemunha não forneceu elementos de que o réu cometeu o delito e não foram juntadas fotos ou filmagens internas; 4)- como afirmado pela testemunha, são revistados três sentenciados por vez, ficando cada um a uma distância de meio metro a um metro do outro; 5)- a hipótese é de crime impossível, pois todos os presos são revistados. Pediu a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da tentativa, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03 e pelo auto de apreensão de fls. 04 (um aparelho celular Samsung com bateria e sem chip e um carregador para telefone móvel).

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída ao acusado.

Em juízo, a testemunha Kunio Ikeda, agente de segurança penitenciária, afirmou que, durante a revista, após o réu tirar toda a roupa, em seu calçado foram localizados um aparelho celular e um carregador. Como a revista é feita em um sentenciado por vez, pode concluir que o calçado era do acusado. Enquanto um agente revista um sentenciado, um segundo agente revista outro e um terceiro agente, mais um sentenciado. Depois da revista, os três são liberados e chamam-se mais dois ou três. Os sentenciados ficam um ao lado do outro durante a revista. Os demais, ainda a serem revistados, ficam em outro local. Há um agente para revista de cada sentenciado. Se há menos de três agentes, os presos ficam isolados, de modo a ser possível que se reviste um de cada vez. Cada sentenciado fica a uma distância de um metro ou meio metro do outro. O preso tira toda roupa, inclusive zorba e meia. O próprio sentenciado se despe e entrega as vestimentas nas mãos do agente. Após a localização do celular, o réu ficou quieto ou admitiu que o aparelho lhe pertencia. Foi seu colega quem encontrou o celular. Estava ao lado e viu.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

A prática do delito foi confirmada pelo depoimento insuspeito de um agente de segurança penitenciário, que flagrou o réu portando o aparelho celular em seu calçado.

As afirmações do servidor público se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários:

"(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone

celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Prosseguindo, nada obstante o fato de os sentenciados, em grupos de três, fossem mantidos durante a revista a uma distância de um metro ou meio metro cada, não se pode cogitar de troca de calçados entre um e outro.

Isto porque, se isso tivesse ocorrido, o fato não passaria despercebido por ao menos dois agentes pois, como se depreende do depoimento da testemunha Kunio, sempre há um agente para revista de cada sentenciado.

Destarte, para que se pudesse falar em troca de calçados, tanto o agente que estivesse revistando o réu como o agente que estivesse procedendo a revista do outro sentenciado ao lado teriam que ter deixado de perceber fato visível.

Não bastasse e colocando uma pá de cal na questão, a testemunha Kunio também disse que, segundo o procedimento de revista, o próprio sentenciado se despe e entrega as vestimentas nas mãos do agente.

Assim é que, estando o agente na posse das vestimentas, inclusive calçados, de um determinado sentenciado que está submetendo a revista, não seria lógico pensar que, na posse daquele, estariam os calçados de outro detento.

Portanto, o fato descrito na denúncia e respectiva autoria estão bem demonstrados. Noutro aspecto, ao contrário do que alega a defesa, não há a necessidade de comprovação do funcionamento dos aparelhos mediante perícia para configuração do delito.

Nesse sentido:

"JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. ART. 349-A CP. INGRESSAR, SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MERA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA.CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 349-A DO CP. NON BIS IN IDEM. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E PENAL. SENTENÇA MANTIDA (...) 2. Trata-se de crime formal, o qual não exige outros desdobramentos para se caracterizar. O simples fato de o agente adentrar os portões do estabelecimento penal portando aparelho celular, sem autorização legal, já constitui o tipo penal (art. 349-A do CPB), ainda que a eficiência do objeto não tenha sido aferida por laudo técnico-pericial(não confeccionado), e mesmo que o aparelho não chegue ao contato de outros detentos, sendo ainda dispensável a prova de que o aparelho seria usado para fins ilícitos." (APJ 20150110399057. TJDF. 2ª T. Recursal. j. em 15/03/2017. Relator: João Fischer)

Ademais, pela própria lógica, é possível afirmar que o aparelho funcionava.

O acusado não se submeteria ao risco de ser capturado em flagrante, ser apenado administrativamente e responder a processo criminal apenas para levar para o interior da unidade prisional um telefone ineficaz para comunicação com o mundo externo.

Tampouco há que se falar em crime impossível, sob argumento de que, como todos os detentos são revistados ao entrar ou sair da unidade prisional, o réu não conseguiria introduzir o aparelho no presídio.

Na verdade, o acusado teria atingido sua finalidade se contasse com a conivência ou negligência dos agentes de segurança penitenciária.

Aliás, a própria experiência contradiz o argumento da defesa, pois se sabe que, constantemente, são encontrados aparelhos da espécie no interior de unidades prisionais.

Ainda, em caso análogo, assim se orienta a jurisprudência:

"Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por fragilidade probatória ou, quando não, pelo reconhecimento de crime impossível, ante a absoluta ineficácia do meio empregado pela ré para transportar o entorpecente para o interior do presídio, tendo em vista o procedimento de revista ao qual seria submetida. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação. Eficácia, ademais, do meio empregado pela ré para a prática do tráfico. Reincidência específica, não reconhecida em primeiro grau, bem comprovada nos autos. Recurso ministerial provido, para aumentar as

penas, e improvido o apelo defensivo." (TJSP, Apelação n. 0076838-45.2010.8.26.0224, rel.Sérgio Coelho, j. 29/11/2012).

Por último, não assiste razão à defesa ao pugnar pelo reconhecimento da tentativa. Deriva da prova que o réu foi flagrado na posse de aparelho celular quando submetido à revista pessoal.

Certamente, a revista pessoal em que os presos se despem totalmente é realizada dentro da unidade prisional e não no ambiente exterior.

Vale a pena se reportar, de resto, ao julgado acima colacionado que trata não somente da prescindibilidade da perícia, como também da inviabilidade do reconhecimento da tentativa em casos que tais (APJ 20150110399057. TJDF. 2ª T. Recursal. j. em 15/03/2017. Relator: João Fischer).

Logo, pode-se afirmar que o réu "ingressou" em estabelecimento prisional com aparelho telefônico de comunicação móvel, de modo que se cuida, aqui, de crime consumado.

Em suma, a condenação na forma proposta na denúncia é medida de justiça.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu ostenta mau antecedente (fls. 130/131 - artigo 155, § 4º, incisos III e IV, combinado com artigo 14, inciso II, Código Penal; e artigo 19, Lei das Contravenções Penais).

Diante disso, fixa-se a pena base em um oitavo acima do mínimo legal, resultando em três meses e onze dias de detenção.

O réu é reincidente (fls. 57/58 e 125 - art. 121, §2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal; e fls. 59/60 - art. 121, §2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II do CP).

Em face da agravante, eleva-se a pena na proporção de um quinto, resultando em quatro meses e um dia de detenção.

Não havendo outras modificadoras, tal pena é a definitiva.

Diante dos antecedentes criminais, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

É inviável, outrossim, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

Com efeito, não é socialmente recomendável que agente já condenado por dois crimes anteriores de homicídio doloso e que comete novo delito durante cumprimento de pena e nas dependências de estabelecimento prisional (onde deveria imperar a ordem e a disciplina, a bem da ressocialização dos que ali estão) seja agraciado com a substituição em comento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Ubiratan Ricardo Gonçalves Portugal como incurso nas penas do artigo 349-A do Código Penal, a cumprir quatro meses e um dia de detenção, em regime inicial semiaberto.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Quanto aos bens apreendidos, são daqueles cujas posses, por si sós, não configuram fato ilícito. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, os bens deverão ser doados ou inutilizados, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

P.R.I.

Bauru, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA